Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Judicial da Comarca de Guarani das Missões

Av. São Miguel, 1035 - Bairro: Centro - CEP: 97950000 - Fone: (55)3029-9961 - Balcão Virtual: (55) 99727-0224 - Email: frgmissoesvjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5000589-27.2023.8.21.0102/RS

AUTOR: VERONICA SUSKI DONATO DA SILVA

RÉU: UNIMED MISSOES - SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDI

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

VERONICA SUSKI DONATO DA SILVA ajuizou ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento c/c indenização por danos morais em face de **UNIMED MISSOES - SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDI**, ambos qualificados nos autos do processo em epígrafe.

Narrou a autora, na inicial, que foi diagnosticada com obesidade infantil (CID 10 - E66), sendo indicado pela médica que lhe assiste o uso contínuo do medicamento SAXENDA 6MG/ML, pelo tempo que se fizer necessário, até a reversão de seu quadro clínico.

Obtemperou que, não se trata de medicamento e patologia com obrigatoriedade de cobertura para uso ambulatorial/domiciliar (falta de cobertura), não coberto pelo rol de procedimentos e eventos de saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS -, houve negativa no fornecimento do equipamento por parte da ré.

Pleiteou, assim, a concessão de tutela provisória de urgência para determinar à ré o fornecimento imediato do supramencionado medicamento enquanto durar o tratamento médico do autor.

No mérito, postulou a procedência do pedido para tornar definitiva a medida antecipatória de tutela. Requereu, por fim, a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Anexou procuração e documentos (evento 1, INIC1).

Indeferido pedido de tutela de urgência por não haver informações acerca do pactuado entre as partes, uma vez que não acostado ao feito o contrato celebrado, somado ao fato de o medicamento não estar regulamentado pela ANS (evento 3, DESPADEC1).

Citada, a ré contestou (evento 12, CONT1). Pontuou o caráter domiciliar do fármaco postulado. Disse que, não se tratando de antineoplástico, a oferta de medicamento domiciliar está expressamente excluída do contrato, o que mencionou estar referendado pelo art. 10, inciso VI, da Lei n.º 9.656/98, não sendo ponto excepcionado pelo art. 12 da mencionada lei. Discorreu sobre a legislação aplicável. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos formulados. Juntou documentos.

Houve réplica (evento 15, RÉPLICA1).

Indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita (evento 17, DESPADEC1).

A parte autora interpôs agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, ao qual foi dado provimento para deferir a medida (evento 19, ACOR2).

Intimadas as partes para manifestarem interesse na produção de provas (evento 28, DESPADEC1).

As partes pugnaram pelo julgamento antecipado do mérito (evento 33, PET1 e evento 34, PET1).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a fundamentar.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O feito teve tramitação regular. Estão presentes os pressupostos processuais de existência e validade. Da mesma forma, não há nulidades arguidas pelas partes ou passíveis de conhecimento de ofício sem que se incorra em decisão surpresa. Não há diligências imprescindíveis que possam levar à conversão do julgamento em diligência. Logo, está o feito apto a julgamento.

A) DO JULGAMENTO ANTECIPADO

O presente feito deve ser julgado antecipadamente, na forma da regra contida no art. 355, I, do CPC/2015, que assim estabelece:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

In casu, a matéria prescinde de maior dilação probatória, especialmente ante a documentação carreada aos autos, que retrata toda a relação jurídica havida entre as partes e permite examinar o contexto objeto de litígio.

Ademais, as próprias partes foram instadas a se manifestar quanto ao interesse em outras provas, ocasião em que pediram o julgamento antecipado.

Assim, aceitaram suportar eventual aplicação da regra do art. 373 do CPC para o caso de não terem se desincumbido de eventual ônus que lhes era carreado.

B) DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamento c/c indenização por danos morais por meio da qual objetiva a parte autora a determinação que a requerida autorize e custeie integralmente o tratamento da autora, com o uso do medicamento SAXENDA 6MG/ML, pelo tempo que perdurar o tratamento.

Passo à análise pormenorizada, item a item, de forma a tornar mais claro seu exame ao jurisdicionado e, eventualmente, às instâncias recursais.

B.1) DA APLICAÇÃO DO CDC

No caso em exame há aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. A parte autora é destinatária final do serviço de plano de saúde à luz do art. 2º do CDC.

Por sua vez, a operadora do plano de saúde é prestadora de serviços no mercado de consumo, fazendo-o mediante remuneração (art. 3º, caput e §2º, CDC).

Nesse cenário, para responsabilização do fornecedor, basta a comprovação da falha na prestação do serviço, do dano suportado pelo consumidor e no nexo de causalidade existente entre ambos, sendo desnecessário perquirir-se dolo ou culpa. A exclusão de responsabilidade, por outro lado, pressupõe a comprovação da ausência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Formatada, portanto, a relação de consumo, há a incidência da legislação consumerista.

B.2) DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

A inversão do ônus da prova, à luz do art. 6º, VIII, do CDC já foi analisada.

Na regra do art. 6º, VIII, CDC, o ônus probatório é invertido "quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação OU quando for ele hipossuficiente".

Considerando que tal matéria já restou decidida e não aportaram novos elementos em sentido contrário (inverossimilhança ou capacidade econômica, informacional, probatória etc.), há de se manter o quanto foi decidido a respeito.

Saliento, ademais, que seria descabida nova inversão do ônus, sobretudo neste momento, dado que seriam alteradas as regras do jogo sem permitir às partes a desincumbência dos ônus que passariam a recair sobre seus ombros.

Logo, segue a análise do feito à luz da inversão já determinada.

C) DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO

No caso, a existência de relação contratual entre as partes, além de incontroversa, está demonstrada pelos documentos anexados aos autos.

Embora o laudo médico anexado pela parte autora descreva, pormenorizadamente, a necessidade de utilização do medicamento SAXENDA 6MG/ML ao seu tratamento, o contrato de assistência à saúde do qual é beneficiária estabeleceu, expressamente, a exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar (evento 12, ANEXO2).

Vejamos:

III. EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES A. DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula 14: Estão expressamente excluídos deste contrato, não gerando direito a qualquer tipo de cobertura, sem prejuízo das limitações previstas nas cláusulas subseqüentes:

*1.27 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESTRANGEIROS OU QUE NÃO ESTEJAM NACIONALIZADOS, BEM COMO DE **TODO E QUALQUER TIPO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR**;*

Acerca dos medicamentos e insumos de uso domiciliar, a Lei n.º 9.656/98 incluiu dentre as coberturas obrigatórias apenas aqueles destinados a tratamento antineoplásico oral (e correlacionados), à medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim, *in verbis:*

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;

Cabe salientar que o caso não se enquadra nas exceções previstas no artigo 12 da Lei n.º 9.656/98, que assim dispõe:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;

II - quando incluir internação hospitalar:

g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;

Ademais, assim dispôs a Agência Nacional de Saúde Suplementar na Resolução Normativa n.º 465 de 2021:

Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998.

Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13;

De se ressaltar que a orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do STJ que tratam da matéria (RESP n.º 1.692.938 - 3ª Turma e n.º 1.883.654 - 4ª Turma) é no sentido de que os planos de saúde não estão obrigados ao fornecimento de medicamento de uso domiciliar, como previsto no artigo 10 da Lei n.º 9656/98, exceto os relativos ao tratamento de câncer, que são de fornecimento obrigatório em razão de expressa disposição legal, não sendo essa a hipótese dos autos.

Conclui-se, portanto, que o plano de saúde demandado não está obrigado a fornecer o medicamento postulado.

Esse é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em casos análogos:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA. DEVER DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. **TOFACITINIBE.** TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC AUSENTES. DECISÃO REFORMADA. - Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos insculpidos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, deverá ser revogada a tutela de urgência anteriormente deferida à parte agravada, pela **ausência** dos requisitos supra. - **O fármaco Tofacitinibe 5mg é de uso domiciliar, e portanto não é, a princípio, de fornecimento obrigatório pelos planos de saúde. Ademais, se constata a existência de diversas notas técnicas na plataforma e-NatJus com conclusão desfavorável ao fornecimento da medicação.** - Recurso provido para revogar a tutela de urgência anteriormente deferida. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 52828710820238217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 23-11-2023) - grifei.*

*APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE ALOPÉCIA AREATA. **MEDICAMENTO TOFACITINIBE. USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. NEGATIVA DE COBERTURA QUE NÃO SE MOSTRA ABUSIVA.** 1) Ausente comando, pelo Superior Tribunal de Justiça, que imponha o sobrestamento dos processos que envolvam a discussão versada nos EREsp1.886.929 e EREsp 1.889.704, a preliminar deve ser desacolhida. 2) Tratando-se de contrato regulamentado, devem ser observadas as coberturas mínimas definidas na Resolução Normativa nº 428/2017, atual RN 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS), que apresenta Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, a qual não pode prever aquelas excetuadas no artigo 10 da Lei nº 9.656/98 e, também, não pode excluir ou mitigar as hipóteses do artigo 12 do mesmo diploma legal. 3) É lícito que se excetue o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar - administração em ambiente externo ao de unidade de saúde (não abrangido o home care) -, salvo os antineoplásicos, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, bem como os serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente (Arts. 10, incs. V e VI e 12, da Lei nº 9.656/98). 4) A vedação constante no artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998, voltada à operadora de plano de saúde, não obsta que, na contratação, atendidos os requisitos regulatórios, as partes incluam dentre as coberturas obrigatórias os medicamentos de uso domiciliar, tendo em vista o princípio da autonomia da vontade, relativo à liberdade contratual. Ademais, é possível a contratação acessória de cobertura de medicamentos domiciliares, de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN nº 310/2012 da ANS. 5) **Caso dos autos em que o medicamento postulado, "Tofacitinibe 5 mg (Xeljanzt®)", indicado para o tratamento de Alopécia Areata (CID L-63.9) que acomete a autora, é de uso oral e destinado à ministração domiciliar. 6) Considerado que não há no contrato principal previsão acerca da obrigatoriedade de cobertura de medicamentos domiciliares, bem como que não há notícias de contratação acessória, nos termos da RN 310/2012, inexiste qualquer abusividade na negativa de cobertura ofertada pela operadora do plano de saúde.** Alteração de posição em atenção aos recentes julgados da Corte Superior (REsp 1692938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021). NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.(Apelação Cível, Nº 50087420520218210010, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 28-07-2022) - grifei.*

Portanto, não vislumbro abusividade na negativa de cobertura feita pela demandada, razão pela qual não prospera o pedido de obrigação de fazer.

D) DOS DANOS MORAIS

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, também não merece prosperar.

Isso porque, para que haja um dano moral, é necessária a violação aos direitos da personalidade. Não é a dor, humilhação, vergonha que ensejam essa reparação por dano extrapatrimonial, na medida em que são situações que variam em cada indivíduo e mesmo não havendo qualquer das suas manifestações em uma determinada pessoa é possível a reparação de uma violação aos direitos da personalidade ou da sua dignidade. Como essas manifestações são consequências daquelas violações, sequer precisam ser provadas e não constituem danos morais.

É necessário olhar para o fato e ver se algum dos direitos da personalidade (vida, saúde, integridade física, imagem, etc.) ou da dignidade da pessoa humana (aquele conjunto de bens mínimos que formam o ser humano) foram violados de forma a aquilatar se há ou não o dano alegado.

Deve-se atentar para a violação desses direitos e ela é que deve ficar, ao fim e ao cabo, provada no feito.

Mas na hipótese dos autos não se percebe a violação de qualquer direito da personalidade do autor, tampouco da sua dignidade.

Cumpre ressaltar que nem mesmo houve comprovação de ilicitude da conduta imputada pela parte demandante à ré, tudo não passando de experiência comum à vida em sociedade e em um Estado de Direito, motivo pelo qual não merece prosperar o pedido indenizatório.

Dessa forma, não havendo lesão aos direitos da personalidade da parte autora ou a sua dignidade, não há que se falar em danos morais.

Nessa senda:

> *Apelação cível. Seguros. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Plano de saúde não regulamentado pela Lei 9.656/98. Inaplicabilidade da Lei 9.656/98 aos planos não regulamentados que impede a extensão da cobertura prevista para o plano de referência, instituído pela referida norma, aos planos anteriores. Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 10 § 2º e 35-E da Lei 9.656/98 que estendiam sua aplicação aos planos antigos. Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 1931. Tratando-se de contrato não regulamentado devem ser estritamente observadas as previsões contratuais a respeito das coberturas previstas e expressamente excluídas. (...).* ***Dano moral. Não caracterização. A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, baseada em cláusula, segundo sua interpretação contratual. Danos morais não comprovados.*** *Apelo da autora não provido. Apelo da ré parcialmente provido. Por maioria." (Apelação Cível Nº 70078057593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 19/10/2018).*

III - DISPOSITIVO

Pelo exposto, **JULGO IMPROCEDENTE** os pedidos formulados por **VERONICA SUSKI DONATO DA SILVA** em face de **UNIMED MISSOES - SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDI**, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Diante do resultado do julgamento, condeno o autor ao pagamento das custas e das despesas processuais e ao pagamento de honorários sucumbenciais aos procuradores da parte adversa, os quais, observado o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade judiciária concedida em sede de agravo de instrumento (evento 19, ACOR2).

Publicação e registro eletrônicos.

Intimação agendada.

Sobrevindo recurso de apelação, intime-se o recorrido para contrarrazões e, após, independentemente de conclusão, remeta-se o feito ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Documento assinado eletronicamente por **GIOVANE GETULIO MENEGAZ, Juiz de Direito**, em 29/8/2024, às 18:34:4, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10064544862v6** e o código CRC **6a799b32**.